

2013년도 제50회 변리사 2차 시험 특허법 해설

안녕하세요! 한빛변리사학원의 김남혁 · 장현욱 변리사입니다.

지난 몇 개월간 인고의 시간을 거쳐, 힘겹게 시험을 치르시느라 정말 수고하셨습니다.

먼저, 여러분들 모두 끝까지 포기하지 않고 정진하셨기에,

영광의 날에 인고의 향이 물씬 베어 있는 열매를 맺게 되시길 진심으로 기원합니다.

시험장에서의 체감난이도와는 차이가 있을 수 있겠으나,

전체적인 난이도는 작년 및 재작년에 비해 다소 어렵게 출제되었다고 판단됩니다.

출제 된 논점의 영역 자체는 여러분들 모두 각종 GS에서 어느 정도 경험해 본 부분일 것이나,

구체적으로 판단하여 작성해야 했던 내용들은, 평상시에 자주 다루어보지 않을 법한 내용들이었기에,

문제를 접하셨을 때 그 내용 및 문제의 길이 등으로 인해 적잖게 당혹감을 느끼셨을 것이라고 생각합니다.

이러한 상황을 바탕으로 예견해 볼 때,

많은 분들께서 평소 실력을 유감없이 발휘하기는 어려웠을 것이라는 판단이 들기 때문에,

여러분들께서 문제에서 묻고자 하는 주 논점에 대해서 정확하게 파악하고,

주어진 법전 및 알고 있는 특허법 지식을 활용하여 어느 정도 적절히 기재하셨다면,

일부 논점에 대해서는 누락하셨더라도, 일정 수준 이상의 점수는 기대해 볼 수 있을 것이라는 생각이 듭니다.

이하에는, 2013년 제50회 변리사 2차 시험의 특허법에 대한 풀이답안이 있습니다.

본 풀이답안은, 한빛변리사학원의 특허법 전임강사인 김남혁 변리사와 장현욱 변리사가 함께 검토하였으며, 이는 어디까지나 예시 답안일 뿐이오니 설혹 이하의 내용에 본인이 답안지에 작성하지 않은 내용이 포함 내지는 불포함 되어 있다거나, 논점을 전개하는 흐름에 있어 다소간의 차이가 있다 하더라도 심리적으로 크게 동요하실 필요는 없습니다. 그러므로 스스로의 논리를 믿으시면 분명히 좋은 점수를 받으실 것이라고, 강사가 아닌 선 경험자의 입장에서 말씀 드리고 싶습니다.

다시 한번 정말로 수고하셨다는 말과 함께,

여러분들 모두에게 제50회 변리사시험 합격의 영광이 있기를 진심으로 기원합니다.

김남혁 · 장현욱 변리사 드림

<A - 1문>

[문 제]

甲은 영어로 된 아래의 [명세서] 및 [청구의 범위]로 한국특허청을 수리관청으로 PCT출원을 2011년 6월 1일자로 하였다. 이에 대하여 甲은 수리관청으로부터 출원에 도면이 포함되어 있지 않다는 취지의 통지를 받았으나, 본 발명이 물질 발명에 관한 것으로 도면이 필요 없다는 취지로 상기 통지에 대한 의견을 지정기간 내인 2011년 8월 5일자로 제출하였다.

[명세서]

실시예 1은 A 또는 a 수단에 의하여 반복 배양되는 줄기세포 P에 관한 것이다. 실시예 2는 줄기세포 P를 이용하여 손상된 인간의 세포를 복원시키는 치료 방법에 관한 것이다.

[청구의 범위]

제1항 A 수단에 의하여 반복 배양되는 줄기세포 P

제2항 줄기세포 P를 이용하여 손상된 세포를 복원시키는 치료방법

그 후, 甲은 국제조사기관으로부터 제1항과 제2항은 단일성을 만족하지 않는다는 이유로 추가수수료납부명령을 받았지만 이를 납부하지 아니하였다. 그리고 甲은 국제조사보고서를 받은 후 국제예비심사보고서 작성 전에 국제조사보고서상의 특허요건 및 기재요건을 충족시키고자, [명세서]에 "실시예 3은 줄기세포 P를 이용하여 손상된 동물의 세포를 복원시키는 치료방법에 관한 것이다"를 추가하는 보정을 하였고, [청구의 범위] 제1항에는 "a 수단에 의하여 반복 배양되는 줄기세포 P"로 보정(단, a는 A의 하위개념임)을 하였고, 제2항에는 "줄기세포 P를 이용하여 손상된 동물의 세포를 복원시키는 치료방법"이라고 동물로 한정하는 보정을 하였다.

甲은 국제예비심사보고서를 받고 지정국인 한국특허청에 국내절차를 진행하려고 한다. 위 사실만을 근거로 다음 물음에 답하시오.

- (1) 甲이 도면을 제출하지 않은 경우의 법적 효과에 대하여 국제출원일과 연계하여 설명하시오. (5점)
- (2) 甲이 지정국에 국내절차를 진행하는 경우 제출해야 할 서류에 대하여 설명하시오. (7점)
- (3) 국내절차의 심사관 입장에서, 국제예비심사단계에서 이루어진 보정에 대한 적법성의 여부를 설명하시오. (12점)
- (4) 甲이 국제조사기관의 단일성 판단에 대한 추가수수료납부를 하지 아니한 경우의 법적효과를 설명하고, 국제조사기관에서의 단일성 판단결과가 지정국의 심사관에 미치는 영향에 대하여 설명하시오. (6점)

[해 설]

I. 설문(1)에 대하여 - 도면부제출의 법적효과가 국제출원일 인정에 미치는 영향 (5)

1. 국제출원일 인정요건(法194조1항) 및 甲의 PCT출원의 국제출원일 검토

(1) 국제출원일 인정요건

국제출원의 국제출원일은, ①출원인성명 ②지정언어 ③ 주체적요건 ④ 명세서 및 청구범위 기재 ⑤ 국제출원의 표시 ⑥지정국 지정이 모두 포함된 국제출원서가 수리관청에 도달한 날로 인정된다.

(2) 사안의 경우

상기 ①~⑥ 모두 특별한 문제 없는 바, 원칙적으로 국제출원일은 국제출원서가 수리관청에 도달한 11년6월 1일로 인정된다.

2. 도면 부제출과 국제출원일 인정과의 연관관계 (法194조3항, 4항, 시행규칙99조의2)

i) 다만, 국제출원의 도면이 누락된 경우 특허청장은 그 취지를 통지 하여야하고, 2개월 이내에 누락된 부분을 제출토록 보완을 명하며, 기간 내에 ii) 도면이 도달하는 경우에는 그 도면의 도달일을 iii) 도면이 도달하지 않는 경우에는 도면에 관한 기재가 없는 것으로 보되 해석상 그러한 국제출원서가 수리관청에 접수된 날을 국제출원일로 인정한다.

3. 설문(1)의 해결 - 도면 부제출의 법적효과 및 그 효과가 국제출원일 인정에 미치는 영향

설문의 경우, 甲은 취지통지를 받은 이후에도 의견서만 제출하고 도면은 제출하지 않았으므로, 甲의 국제출원서는 다른 보완사유가 없다면 도면 부제출에 따른 법적 효과로서 法194조4항에 따라 도면에 관한 기재가 없는 국제출원서로 인정될 것이다. 또한, 甲 출원의 국제출원일은, 도면 부제출에 따른 효과에 영향없이 수리관청인 한국특허청에 국제출원서가 접수된 2011년6월1일로 확정될 것으로 판단된다.

II. 설문(2)에 대하여 - 국내단계 진입위한 제출서류 및 PCT 34조 보정서에 대한 번역문 제출 (7)

1. 문제의 소재

2. 甲이 국내단계 진입을 위해 제출해야 할 서류

(1) 法203조1항 각호의 사항이 기재된 서면의 제출(法203조1항, 3항)

1) 국제특허출원을 외국어로 출원한 출원인은, 제203조 1항 각호의 사항을 기재한 서면을 특허청장에게 제출하여야 한다. 상기 서면을 제출하지 않거나, 방식에 위반하여 제출하는 경우 특허청장은 당해 국제특허출원을 무효로 할 수 있다.

2) 설문의 경우, 甲은 외국어인 영어로 국제특허출원을 하였는바, 적법한 국내단계 진입을 위하여, 국내서면제출기간 내 法203조1항 각호의 서지적 사항이 기재된 서면을 제출하여야 할 것이다.

(2) 명세서 등의 번역문 (法201조1항, 2항)

1) 국내서면제출기간 내에 명세서, 청구의 범위, 도면(설명부분) 및 요약서의 번역문을 제출하여야 한다. 이 때, 명세서 및 청구의 범위에 대한 번역문을 제출하지 않은 경우에는 당해 국제특허출원은 취하된 것으로 본다.

2) 설문의 경우, 甲의 출원이 적법한 국내단계로의 진입을 위해서는, 法201조1항에 따라 명세서·청구의 범위 및 요약서에 대한 번역문을 제출해야 한다.

3. 甲이 국제단계에서 행한 ‘보정’이 적법하게 취급되기 위해 제출해야 할 서류 - PCT 34조 보정서 번역문

(1) 甲이 국제단계에서 행한 보정의 유형 - PCT 34조 보정

설문의 경우, 甲은 i)청구범위 뿐만 아니라 명세서에 관해서도 추가하는 보정을 ii)국제조사보고서를 받은 후 국제예비심사보고서 작성 전 행하였으므로, 甲의 보정은 청구의 범위에 대해서만 보정이 가능한 PCT 19조 보정이 아닌 국제예비심사보고서 작성 전까지 청구의범위 외 명세서 등 모두에 대해 보정 가능한 PCT 34조 보정으로 판단된다.

(2) PCT 34조 보정서의 국어 번역문 제출(法205조1항, 3항)

1) 외국어로 국제특허출원한 출원인은 PCT 34조에 따라 보정을 한 경우, 기준일까지 보정서의 국어 번역문을 제출해야 한다.

2) 설문의 경우, 외국어인 영어로 출원한 甲은 앞서 검토한 바와 같이 국제단계에서 PCT 34조에 따른 보정을 진행하였는 바, 기준일까지 PCT 34조 보정에 대한 국어 번역문을 제출하여야 할 것이다.

4. 설문(2)의 해결

설문의 경우, 甲은 지정국에 국내절차를 진행하는 경우, i)法203조1항 각호의 사항을 기재한 서면, ii) 명세서 등의 번역문 iii) PCT 34조 보정서에 대한 국어 번역문을 제출하여야 하며, iv) 별도로 기준일을 확정하기 위하여는 수수료 납부하는 행위 외에 심사청구서도 제출하여야 할 것이다.

III. 설문(3)에 대하여 - PCT 34조 보정의 적법 여부 판단 (12)

1. 문제의 소재 - 국제단계에서의 보정

2. 甲이 국제예비심사단계에서 행한 보정의 유형 - PCT 34조에 따른 보정

(1) 출원인은 국제예비심사보고서 작성 전, 청구의 범위, 명세서 등에 대하여 횡수에 제한없이 국제예비심사기관에 대하여 보정을 행할 수 있다.

(2) 설문의 경우, 甲은 국제예비심사보고서 작성 전, 청구항 1항 및 2항과 명세서를 보정하였으므로 甲이 행한 보정은 국제예비심사단계에서의 PCT 34조에 따른 보정이다.

3. PCT 34조에 따른 보정의 국내단계에서의 취급(法205조 1항 및 2항)

- i) 외국어로 PCT 34조에 따른 보정 시 출원인은 기준일까지 보정서에 대한 번역문을 제출하여야 하며,
- ii) 이 경우 제출된 번역문에 따라, 法47조1항에 따른 명세서 및 도면이 보정된 것으로 보고 있다.

4. 국제특허출원에 대한 法47조2항의 판단대상 (法47조2항, 法208조3항)

(1) 신규사항 추가 금지(法47조2항)

- 1) 특허법은 제3자에게 불측의 손해를 줄 우려를 막기 위해 보정 시 신규사항 추가를 제한하고 있다.
- 2) 判例는, 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항 및 출원 시 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 최초 명세서 등의 기재내용으로 보아 기재되어 있었던 것으로 인정할 수 있는 사항은 신규사항이 아니라고 판시하였다.

(2) 국제특허출원에 대한 신규사항 추가여부 판단대상

다만, 외국어로 출원된 국제특허출원의 보정에 대해 신규사항 추가인지 여부는, 국제출원일에 제출한 국제특허출원의 청구의 범위, 명세서 등의 번역문을 기초로 하여 새롭게 추가된 것인지를 판단한다.

5. 甲이 국제예비심사단계에서 행한 보정의 적법성 여부 판단

(1) 청구항 제1항 - 적법

설문의 경우, 甲이 PCT 34조 보정에 따라 청구항 1항의 'A 수단'을 그 하위개념인 'a 수단'으로 한정시킨 보정은, 'a 수단'이 국제출원일에 제출한 국제특허출원 명세서의 번역문에 기재된 것인 바 法47조2항을 만족하는 적법한 보정이다.

(2) 청구항 제2항 - 부적법

- 1) 심사지침서는, 의료행위 관련 발명의 청구범위에서 대상이 사람인지 동물인지 명시되어 있지 아니한 경우, 사람에게 해당되는 부분을 삭제하기 위해 청구항을 한정하는 보정은 신규사항 추가로 보지 않고 있다.
- 2) 설문의 경우, 청구항 2항의 '손상된 세포를 복원시키는 치료방법' 중 '손상된 세포'를 '동물의 세포'로 보정한 것은, 형식상 '손상된 세포'의 대상을 '동물'로 한정한 것이나, 甲의 국제특허출원 명세서의 번역문에는 오로지 '인간의 세포'만을 개시하고 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 당해 甲의 보정은, 통상의 기술자로부터 자명하다고 볼 수 없으므로 신규사항 추가에 해당하는 부적법한 보정이라고 판단된다.

(3) 명세서에 실시예 3을 추가하는 보정 - 부적법

설문의 경우, 국제특허출원 명세서의 번역문에 오로지 '인간의 세포'를 복원시키는 치료방법만이 기재되어 있으므로, '동물의 세포'를 복원시키는 치료방법인 실시예 3을 추가하는 甲의 보정은, 앞서의 청구항 2항과 같은 취지로 신규사항 추가에 해당하는 부적법한 보정이라고 판단된다.

5. 설문(3)의 해결

설문에서 甲이 국제예비심사단계에서 행한 보정 중 청구항 1항에 대한 보정은 국제출원일에 제출한 국제특허출원 명세서의 번역문에 기재된 것인 바 적법한 보정이나, 청구항 2항 및 실시예 3을 추가하는 명세서에 대한 보정은 국제특허출원 명세서의 번역문에 기재되지 않은 사항을 추가하는 것으로서, 인간의 세포로부터 동물의 세포에 이르는 과정이 통상의 기술자에게 자명하다는 특별한 사정이 없는 한, 신규사항 추가에 해당하여 法47조2항을 위반한 부적법한 보정이다.

IV. 설문(4)에 대하여 – 특허법 시행규칙 제106조의14 및 국제조사보고서 등의 구속력 인정여부 (6)

1. 문제의 소재

2. 국제조사기관의 단일성 판단에 대한 추가수수료 불납의 법적효과 – 특허협력조약 제17조(3)(a)

(1) 특허법 시행규칙 106조의14 – 발명의 단일성 불만족시의 취급

심사관은 국제출원이 발명의 단일성을 만족하지 않는다고 간주되는 경우, 추가수수료 납부를 명하고(1항), 추가수수료를 납부한 경우에는 당해 발명에 대해 국제조사를 진행하며(2항), 추가수수료를 납부하지 않은 경우에는 청구범위에 가장 먼저 기재된 1군의 발명에 관련되는 국제출원부분에 한하여 국제조사보고서를 작성하게 된다(3항).

(2) 사안의 경우

甲이 국제조사기관의 단일성 판단에 대한 추가수수료를 납부하지 아니한 경우, 甲의 출원은, 청구범위에 가장 먼저 기재된 발명에 관계되는 국제출원 부분에 한하여만, 심사관이 국제조사보고서를 작성하게 되는 법적 효과를 받게 된다.

3. 국제조사기관에서의 단일성 판단결과가 지정국 심사관에 미치는 영향 – 구속력이 인정되는지 여부

(1) 국제조사기관의 국제조사보고서 및 견해서

국제조사기관은 국제조사 후 국제출원의 언어로 단일성 판단결과를 포함하는 국제조사보고서 및 견해서를 작성하여야 한다(특허법 시행규칙 106조의19 1항, 3항)

(2) 국제조사보고서 및 견해서의 내용 및 목적

국제조사보고서 및 견해서는 국제출원인이 각 지정국에 대해 국내절차를 개시하기 이전에, 출원의 특허성, 관련 선행기술 존재여부 및 단일성 만족여부 등에 대한 정보를 알려주어, 국내절차 진행 여부를 결정하는데 참고자료로 활용하기 위한 목적으로 작성되는 것이다.

(3) 국제조사보고서 및 견해서가 지정국 심사관의 판단을 구속하는지 여부

국제조사기관에서의 단일성 판단결과는, 국제조사보고서 및 견해서에 포함되어 지정국의 심사관이 고려하게 되므로 이를 참고할 수는 있으나, 파리조약의 3대원칙 중 하나인 속지주의 원칙에 입각하여 각국마다 판단방법이 상이할 수 있어 각 지정국 심사관의 판단을 구속하지 않는다. 따라서, 지정국의 심사관은 국제조사기관에서의 단일성 판단결과에 구애됨이 없이 자유롭게 당해 출원의 단일성 여부를 심사 할 수 있다.

4. 설문(4)의 해결

i) 甲이 국제조사기관의 단일성 판단에 대한 추가수수료를 납부하지 아니한 경우, 청구범위에 가장 먼저 기재된 발명에 관계되는 국제출원 부분에 한하여만 심사관이 국제조사보고서를 작성하게 되는 법적 효과를 받게되며, ii) 국제조사기관에서의 단일성 판단결과는 지정국 심사관의 참고대상은 될 수 있으나, 속지주의 원칙 상 심사관을 구속하지는 못한다.

<A - 2문>**[문 제]**

甲은 아래의 [발명의 상세한 설명]과 [특허청구범위]로 특허출원하였다.

[발명의 상세한 설명]

본 발명은 폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의하여 처리하는 방법에 관한 것이다.
특히 산은 황산(A) 또는 질산(B)으로 구성되는 것이다.

[특허청구범위]

제1항 폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의하여 처리하는 방법
제2항 제1항에 있어서, 산은 황산(A)인 방법

출원인 甲은 특허청으로부터 거절이유통지를 받기 전에 제2항을 "제1항에 있어서, 산은 황산(A) 또는 질산(B)인 방법"으로 보정함과 동시에 심사청구를 하였다. 그 후 甲은 심사관으로부터 "산과 질산(B)"은 이건 출원 전에 반포된 선행문헌으로부터 진보성이 없어 특허법 제29조제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없다는 최후거절이유통지서를 받고, 다음과 같이 특허청구범위를 보정하였다.

[특허청구범위]

제1항 폴리에틸렌수지의 표면을 황산(A)에 의하여 처리하는 방법.
제2항 제1항에 있어서, 황산(A)에 의하여 처리한 후 염산(C)에 의하여 더 처리하는 방법

상기 보정에 대하여, 심사관으로부터 제1항 및 제2항은 특허법 제47조 제2항의 규정에 위배된다는 취지로 보정각하결정서를 받았고, 동시에 이건 출원은 선행기술에 의하여 진보성이 없으므로 특허를 받을 수 없다는 거절결정서를 송달받았다.

위 사례와 관련하여 다음 물음에 답하시오. (단, 기재요건은 적법하고, 염산(C)은 질산(B)에 비해 신규한 것으로 간주함)

- (1) 甲이 거절이유통지를 받기 전에 한 보정의 적법성에 대하여 설명하시오. (5점)
- (2) 심사관이 판단한 보정각하결정의 적법성에 대하여 설명하시오. (7점)
- (3) 甲이 이건 출원을 특허받기 위하여 취할 수 있는 조치에 대하여 설명하시오. (8점)

[해 설]

I. 설문(1)에 대하여 - 자진보정(法47조1항本) 및 신규사항추가금지(法47조2항) (5)

1. 보정의 의의 및 취지(法47조)

특허법은 선출원 주의에 따른 출원미비를 보완하기 위해 보정제도를 두어 출원인이 보호받을 수 있도록 하나, 심사절차의 지연 및 제3자와의 관계를 고려하여 시기 및 내용에 일정한 제한을 두고 있다.

2. 자진보정(47조1항본문) 및 甲의 보정이 자진보정에 대한 시기적 범위를 만족했는지 여부

(1) 출원인은 거절이유통지를 받기 전에는, 法66조에 따른 특허결정등본 송달 전까지 명세서 또는 도면을 자진하여 보정할 수 있다.

(2) 사안의 경우, 甲은 거절이유통지를 받기 전 보정을 행하였는바, 당해 보정은 자진보정에 해당 하며, 法47조1항본문에 따라 자진보정의 시기적 범위를 만족한다.

3. 甲의 자진보정이 신규사항 추가 위반인지 여부 - 자진보정의 객관적 범위 만족 여부

(1) 자진보정의 보정범위 및 신규사항추가 금지(法47조2항)

1) 특허법은 제3자에게 불측의 손해를 줄 우려를 막기위해 자진보정 시 신규사항 추가를 제한하고 있으며, 상기 신규사항추가인지 여부는 당해 보정서를 최초 명세서·도면과 비교하여 자명한지 여부로 판단한다.

2) 判例는, 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있는 사항 및 출원 시 기술수준에 비추어 통상의 기술자가 최초 명세서 등의 기재내용으로 보아 기재되어 있었던 것으로 인정할 수 있는 사항은 신규사항이 아니라고 판시하였다.

(2) 사안의 경우

설문의 경우, 甲은 청구항 2항의 '황산(A)'을 최초 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 '황산(A) 또는 질산(B)'으로 보정하였는 바, 신규사항 추가에 해당되지 않는다.

4. 설문(1)의 해결 - 적법

甲의 거절이유통지받기 전 甲이 행한 자진보정은 적법하다. 따라서, 甲의 청구항 제1항은 '폴리에틸렌수지의 표면을 산에 의하여 처리하는 방법', 청구항 제2항은 '제1항에 있어서, 산은 황산(A) 또는 질산(B)인 방법'으로 확정되어 심사가 진행될 것이다.

II. 설문(2)에 대하여 - 보정각하의 대상 및 보정각하의 타당성 판단 (7)

1. 문제의 소재

2. 보정각하의 의의 및 취지 (法51조)

보정각하는, 이미 행해진 심사결과를 유효하게 활용하여 심사촉진을 도모하기 위해 法47조1항2호 및 3호의 보정이 부적법한 경우, 당해 보정을 결정으로 각하하는 심사관의 행정처분을 말한다.

3. 보정각하의 대상 및 판단방법

(1) 출원인이 法47조1항2호의 기간에 보정한 것이 보정범위인 法47조2항, 3항 또는 法51조1항 중단을 만족하지 못하는 경우 보정각하의 대상이다.

(2) 보정의 범위를 만족하는지는 청구항 별로 판단하나, 일부 청구항이라도 보정의 범위를 만족하지 못하는 경우, 보정각하의 처분은 당해 보정서 전체에 행하여진다.

4. 甲의 청구항 별 보정이 法47조2항의 규정에 위배되는지 여부

(1) 청구항 제1항의 보정이 法47조2항의 규정에 위배되는지 여부 - 적법

甲의 청구항 제1항에 대한 보정은 '황산(A)'이 최초 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 점을 고려할 때 法47조2항의 규정에 위배되지 않는다.

(2) 청구항 제2항의 보정이 法47조2항의 규정에 위배되는지 여부 - 위배

甲의 청구항 제2항에 대한 보정은 '질산(B)'에 비해 신규한 '염산(C)'를 추가하는 보정을 하였는바, 이는 甲의 최초 명세서의 발명의 상세한 설명에 기재되어 있지 않은 신규사항을 추가한 것이므로, 法47조2항의 규정에 위배된다.

5. 설문(2)의 해결 - 청구항 제1항 및 제2항 모두가 法47조2항 위반이라는 취지로 한 보정각하 결정의 타당성

앞서 살펴본 바와 같이 甲의 최후거절이유통지에 대응한 보정은, 오직 청구항 2항에 대한 보정만이 法47조2항에 위배되었음에도 불구하고, 심사관은 청구항 1항 및 2항 모두가 法47조2항에 위배되었다는 잘못된 취지로 보정각하 결정을 하였으나, i) 보정각하의 처분은 청구항 별호가 아닌 보정서 전체를 기준으로 행하여지는 점, ii) 따라서 어차피 청구항 2항에 대한 보정이 法47조2항에 위배되어 보정서 전체가 보정각하라는 동일한 결과에 이를 것이라는 점, iii) 보정각하에 대해서는 별도의 의견서 제출기회를 주고 있지 않은 점을 고려할 때, 잘못된 취지와는 관계없이 당해 보정각하 결정 자체는 적법한 것으로 판단된다.

III. 설문(3)에 대하여 - 거절결정의 타당성 및 재심사·거절결정불복심판의 청구 (8)

1. 문제의 소재

2. 심사관의 거절결정 처분 대상의 확정 - '산과 질산(B)'이 포함된 청구항 제1항 및 제2항

(1) 심사지침서에 따를 때, 최후거절이유통지에 대응한 보정이 보정범위를 위반한 경우, 심사관은 보정을 각하하고 보정 전 명세서로 심사하되 원 거절이유를 극복하지 못한 경우에는 다시 거절이유통지 및 의견서 제출기회를 부여하지 않고 거절결정을 하게 된다.

(2) 설문의 경우, 심사관은 설문(2)에서 검토한 바와 같이 甲의 보정을 각하한 후, 보정 전 명세서를 토대로 하여 심사를 하게 되는 바, 청구항 제1항 및 제2항에 '산과 질산(B)'은 여전히 존재할 것이므로 심사관의 거절결정 처분의 대상은 '산과 질산(B)'이 포함된 청구항 제1항 및 제2항으로 확정된다.

3. 甲이 이건 출원 '자체'를 특허받기 위하여 취할 수 있는 조치

(1) 보정을 수반한 재심사 청구(法63조의2)

- 1) 甲의 특허출원이 09.07.01이후 출원이라면, 甲은 i) 거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내 ii) 보정을 수반하며 iii) 재심사 청구서를 제출하면, 재심사 절차를 통해 등록을 도모할 수 있을 것이다.
- 2) 수반할 보정서와 관련, i) '산'을 최초 명세서에 기재된 '황산(A)'으로 감축하는 보정을 하고, ii) 진보성이 없는 '질산(B)'을 삭제보정 할 수 있을 것이다.
- 3) 다만, 심사관은 '산'을 '황산(A)'로 감축하는 보정과 관련하여, 신규사항 추가에 위배된다는 잘못된 취지의 판단을 행한 바 있으므로, 설문(2)에서 살펴본 바와 같이 '산'을 발명의 상세한 설명에 기재된 '황산(A)'으로 감축하는 보정은 신규사항 추가가 아니라는 취지의 의견서를 함께 제출하여야 할 것이다.
- 4) 따라서, '황산(A)'에 대한 발명으로 감축하는 보정서 및 상기 의견서를 수반하여 재심사 청구할 경우, 甲의 출원은 다른 거절이유가 없다면 특허받을 수 있을 것이다.

(2) 거절결정불복심판 청구(法132조의3)**1) 甲의 특허출원이 09.07.01이전 출원인 경우**

재심사 청구제도를 활용할 수 없으므로 甲은 i) 거절 결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내 ii) 특허심판원에 거절결정불복심판 청구서를 제출함으로써 불복을 꾀할 수 있다. iii) 또한, 거절결정불복심판 청구일로부터 30일 이내 '황산(A)'에 대한 발명으로 감축하는 보정서를 제출하여, 심사전치제도를 통해 등록을 도모해 볼 수 있으며, 이 경우 다른 거절이유가 없다면 특허받을 수 있을 것이다.

2) 甲의 특허출원이 09.07.01이후 출원인 경우

i) 거절결정불복심판을 청구하여 통상의 기술자가 선행문헌으로부터 당해 발명에 이르는 것이 용이하지 않아 심사관의 거절결정은 부당하다는 것을 주장하여 등록을 도모해 볼 수 있다. ii) 아울러, 보정각하 결정의 타당성을 다투볼 수는 있으나(法51조3항), 설문(2)에서 살펴본 바와 같이 큰 실익은 없을 것으로 본다.

4. 甲이 이 사건 출원에 포함된 '발명'을 등록받기 위하여 취할 수 있는 조치**(1) 분할출원**

09년 개정법에서는 i) 보정을 할 수 있는 기간과는 별도로 ii) 거절결정등본을 송달받은 날로부터 30일 이내에도 분할출원 할 수 있는 것으로 규정한 바, 甲은 최초 명세서에 기재된 '황산(A)'에 대한 발명을 분할출원하여 등록을 도모할 수 있을 것이다.

(2) 변경출원

甲은 보다 낮은 정도의 용이성을 요구하는 실용신안으로의 변경출원을 고려할 수는 있으나, 甲의 발명은 방법발명인 바 실용신안의 대상적격을 만족하지 못하므로, 조치로서 활용할 수는 없다.

(3) 취하 후 재출원 및 우선권주장출원

아직 甲의 출원발명이 공개되었다는 사정이 존재하지 않으므로, 甲은 출원을 취하한 후 황산(A)에 대한 발명을 재출원하거나 당해 출원을 기초로 우선권주장출원을 하여 등록을 도모할 수 있을 것이다.

5. 설문(3)의 해결

설문의 경우, 甲은 가장 큰 실익이 있다고 판단되는 재심사 청구를 통해 이 사건 출원 내지 출원에 포함된 발명을 등록받을 수 있을 것이며, 아울러 거절결정불복심판의 청구, 분할출원 및 취하 후 재출원 등의 조치도 고려해 볼 수 있을 것이다.

<B - 1문>**[문 제]**

이 사건 발명은 "가수분해에 의해 습도를 조절하는 수단"에 관한 것이다. 甲은 이 사건 발명을 특허출원하면서, 청구항 1에 "공기 중 수분을 물방울로 변화시켜 물통으로 배출하는 수단"이라는 기능적 청구항으로 기재하였고, 종속항인 청구항 2 내지 5에 공기 중의 수분을 액체인 물방울로 변화시켜 물통으로 배출하는 수단에 관한 구체적인 구성을 기재하였다. 청구항 1은 발명의 상세한 설명 또는 도면에 의해 명료하게 설명되어 있지 않지만, 종속항인 청구항 2 내지 5의 구성요소만으로 보충·한정하여 해석할 때에는 청구항 1의 수단이 명료해져 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자는 이 사건 발명의 권리범위를 명확하게 특정할 수 있다. 이 사건 발명은 현재 특허등록되어 있다. 이에 대하여, 이 사건 발명을 실시하고자 하는 乙은 이 사건 발명이 기재불비에 해당하여 무효라는 이유로 청구항 1 내지 5에 대해 무효심판을 청구하였다.

- (1) 기능적 청구항의 의의, 필요성, 법적 근거 및 권리범위 해석에 관하여 설명하십시오. (10점)
- (2) 위의 사례와 관련하여 이 사건 발명이 기재불비로서 무효인지의 여부를 판단하십시오. (단, 기재불비 외의 특허거절이유는 고려하지 않기로 함) (20점)

[해 설]**1. 설문(1)에 대하여 - 기능식 청구항의 일반론 (10)****1. 기능식 청구항의 의의**

특허제도는 발명의 공개대가로 독점권을 부여하는 제도이며, 특허청구범위는 발명의 보호범위를 정하는 기준이 된다. 하지만 발명의 특성상 특허청구범위를 구체적인 구조의 기재만으로 표현하기 어려운 경우가 발생하게 되고, 이러한 발명을 특정하기 위해 작용, 기능, 성질 또는 특성 등을 나타내는 기재로 청구항에 표현할 경우, 이를 기능식 청구항(means-plus-function)이라 한다.

2. 기능식 청구항 기재의 필요성**(1) 출원인의 입장**

- i) BM 발명, 생명공학발명 등과 같이 발명의 구조 등을 특허청구범위에 명확히 기재하기 곤란한 경우가 있고 ii) 향후 권리행사를 고려해 청구범위를 넓게 기재하기 위함이다.

(2) 심사관 및 제3자의 입장

기능적 표현을 통해서 상세한 설명을 참고하지 않아도 해당 청구범위를 더욱 분명히 하여 발명을 쉽게 이해할 수 있게끔 하기 위함이다.

3. 기능식 청구항 기재의 법적근거

(1) 구법의 태도 및 심사실무

구 法42조4항3호는 ‘청구범위가 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재할 것’을 요구하여 구성이 아닌 기능으로 표현하였다는 이유만으로 위 규정에 위배될 소지가 있었다.

(2) 개정법의 태도

07년 개정법은 法42조4항3호를 삭제하고, 法42조 6항을 신설하여 특허청구범위의 작성방법의 다양화를 도모하였는바, 특허청구범위는 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조, 방법, 기능, 물질 또는 이들의 결합 관계 등으로 기재할 수 있다고 규정하여 기능식 청구항을 입법적으로 수용하였다.

4. 기능식 청구항의 권리범위 해석

(1) 문제점

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 발명으로 특정되는바(法97조), 기능식 청구항의 경우 청구항에 기재된 모든 기능을 권리범위로 해석할 수 있는지가 문제된다.

(2) 권리범위 해석의 원칙적인 판단방법

判例는 청구범위의 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 권리범위를 제한하여 해석할 수 없다고 하였다.

(3) 권리범위 해석의 예외적인 판단방법

判例는 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 권리범위를 제한 해석할 수 있다고 하였다.

(4) 기능식 청구항의 권리범위 해석의 판단방법

判例는 기능식 표현으로 된 청구항의 권리범위는 청구항에 기재된 기능을 수행하는 모든 구성을 포함하는 것이 아니라, 청구항의 기재와 발명의 상세한 설명 및 도면에 의하여 명확하게 확정되는 구성만을 포함하는 것으로 한정 해석하여야 한다고 하였다.

(5) 제한 해석의 범위에 대한 고찰

i) 제한해석하는 경우 어느 범위까지 제한을 인정하여야 하는지에 대하여 ① 실시예에 한정하자는 견해 ② 실시예에 관련 없이 발명의 상세한 설명과 도면에 기능식 표현과 대응되는 구성으로 기재된 것과 동일하게 볼 수 있는 것까지 인정하자는 견해 ③ 당업자가 용이하게 실시할 수 있는 구성이면 포함시키자는 견해로 나뉜다. ii) 생각건대, 발명의 상세한 설명에 실시예의 형태로만 기재되는 것은 아니므로 ①견해는 부당하고 ③의 견해는 그 기준이 모호하다는 점에서 ②의 견해가 타당하다.

(6) 역균등론 및 입법례

i) 침해대상이 특허발명과 같은 기능을 가지고 있어도 상세한 설명 중에 기재된 실시예와 동일하거나 등가인 구성을 갖추지 않는 경우에는 권리범위를 인정하지 않을 수 있다. ii) 나아가, 미국특허법 112조 6항 하단에서는 기능식 청구항은 그 기능을 전부 포함하는 것이 아니라 실시예와 등가인 것만 한정한다는 취지의 규정을 명문으로 두고 있다.

(7) 검토 및 기능식 청구항의 권리범위 해석에 대한 소결

기능식 청구항을 문언 그대로 해석하는 경우 특허발명의 보호범위가 불분명해지거나 지나치게 넓을 수 있으므로, 제3자와의 관계 및 法97조의 법적 안정성을 고려하여 청구범위를 합리적인 범위에서 제한하여 해석하는 것이 타당하다.

II. 설문(2)에 대하여 - 기재불비에 따른 무효사유의 판단 (20)

1. 문제의 소재

2. 甲의 청구항이 기능식 청구항에 해당하는지 여부

(1) 기능식 청구항의 결정기준¹⁾

특허법에 정의되어 있지 아니한바, 미국 특허법에 의하면 기능식 청구항의 여부를 결정하는 4가지 요건으로는 i) 조합 청구항 ii) 수단이라는 용어의 사용 iii) 기능의 존재 iv) 상응하는 구조의 청구범위에 미기재가 있다.

(2) 사안의 경우

i) 甲의 청구항1은 공기 중 수분을 물방울로 변화시켜 물통으로 배출하는 ‘수단’으로 기재되어 있는바 이는 구조가 아닌 기능적 표현에 해당하므로 기능식 청구항이다. ii) 다만, 甲의 청구항 2 내지 5항은 청구항 1의 ‘수단’에 대한 구체적인 ‘구성’을 기재하고 있으므로 기능식 청구항에 해당되지 않는다.

3. 甲의 기능식 청구항의 기재 형태가 그 자체로 특허법상 기재불비에 해당하는지 여부

(1) 구 법상 판례의 태도

判例는 특허청구범위에는 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 않고, 발명의 기능이나 효과를 기재한 이른바 기능적 표현도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 보이는 경우가 아니면 허용될 수 없다고 하였다.

(2) 개정법의 태도

설문(1)에서 살펴본 바와 같이, 구법에서는 제42조 4항 3호에 위배될 소지가 있었으나, 07년 개정법은 제42조 4항 3호를 삭제하고, 제42조 6항을 신설하여 기능식 청구항을 입법적으로 수용하였다.

(3) 검토 및 사안의 경우

출원인의 편의도모, 기능식 청구항의 회피설계를 방지하는 측면에서 타당한 입법이라고 본다. 따라서 甲의 청구항 제1항은 기능식 청구항이라는 이유만으로 기재불비가 발생하지는 않는다.

1) 미국특허법 제112조(6)

다만, 개정법에 의하더라도 기능식 청구항 자체의 기재가 허용된 것일 뿐, 제42조3항 1호, 제42조4항 1호, 2호의 명세서 기재요건은 별도로 만족 하여야 하는바 이하 살펴보도록 한다.

4. 이 사건 발명이 기재불비에 해당하는지 여부

(1) 특허법상 무효사유가 되는 기재불비의 대상 - 法42조3항1호, 法42조4항1·2호

i) 특허법상 소위 기재불비라 함은, 발명의 상세한 설명에 관한 法42조3항1호와 청구항에 관한 法42조제4항1호 및 2호가 있다. 이들은 거절이유, 정보제공 사유에 해당함은 물론 무효사유에도 해당된다. ii) 다만, 07년 개정법에서 신설된 제42조6항은 청구범위 작성에서의 바람직한 지침에 불과하다.

(2) 다항제에 있어서의 기재불비 판단 방법

1) 法42조 제5항, 특허법시행령 제5조는 청구항 기재에 있어 다항제를 채택하고 있는바, 다항제 아래에서 각 청구항은 독립항이든 종속항이든 상호 독립되어 있어 청구항마다 독자적인 권리범위를 가지므로, 특허요건 및 기재불비 여부도 청구항 별로 따로 판단하여야 한다.

2) 설문의 경우, 甲의 청구항은 독립항인 제1항 및 종속항인 제2항 내지 제5항인 다항제로 기재되어 있으므로, 甲의 발명이 기재불비에 해당하는지 여부는 청구항 별로 판단하여야 할 것이다.

(3) 기능식 청구항인 甲의 독립 청구항 제1항이 기재불비에 해당하는지 여부

1) 특허법원 판례의 태도

判例²⁾는 기능적 표현만으로 되어 불명확한 독립항을 오로지 종속항에서 부가 또는 한정하고 있는 구성요소만으로 이루어진 것으로 보충·한정하여 유효하게 해석하는 것은 허용될 수 없다고 하였다.

2) 검토

생각건대, i) 기능적 표현만으로 되어 스스로의 의미 있는 구성을 갖지 못한 텅 빈 독립항이 오로지 종속항에 의하여 비로소 부가 또는 한정된 구성들로 보충되어 유효하게 될 수 있다고 해석하게 되면, ii) 독립항의 권리범위가 종속항들의 권리범위와 똑같아지거나, iii) 심지어는 여러 개의 하위 종속항을 가지는 독립항이 오히려 하위 종속항들보다 권리범위가 좁아지게 되는 모순이 발생으로 판례의 태도는 타당하다고 판단된다.

3) 사안의 경우

따라서 i) 기능적 표현만으로 된 甲의 독립 청구항 1항의 ‘공기 중 수분을 물방울로 변화시켜 물통으로 배출하는 수단’은, 발명의 상세한 설명과 도면을 참조하여 해석하더라도 그 구성이 명확하지 않고, ii) 종속항인 2항 내지 5항에서 부가·한정된 구성만으로 이루어졌다고 해석할 수밖에 없는 경우에 해당되므로, iii) 독립 청구항 1항은 발명의 필수적 구성요소가 명확하고 간결하게 기재되었다고 볼 수 없어, 法42조3항1호 및 法42조4항1·2호의 규정에 위반된다고 판단된다.

(4) 甲의 종속 청구항 제2항 내지 제5항이 기재불비에 해당하는지 여부

1) 독립항이 기재불비인 경우 종속항도 당연히 기재불비에 해당하는지 여부

判例³⁾는, 다항제 하에서, 독립항이 기재불비에 해당한다고 하여 종속항도 당연히 기재불비에

2) 2005허7354

3) 2005허7354

해당한다고 단정할 수는 없다고 판시한바 있다.

2) 사안의 경우

i) 甲의 독립 청구항 1항이 기재불비에 해당한다고 하여, 종속 청구항인 2항 내지 5항이 당연히 기재불비라고 단정할 수는 없으나, ii) 종속 청구항 2항 내지 5항은, 독립 청구항 제1항의 ‘공기 중 수분을 물방울로 변화시켜 물통으로 배출하는 수단’에 대한 구체적인 구성을 한정한 발명인 바, 상기 수단은 청구항 2항 내지 5항의 필수 구성요소라고 볼 수 있다. iii) 따라서, 청구항 2항 내지 5항의 필수 구성요소인, 청구항 1의 수단이 불명확한 기재에 해당함은 앞서 검토한 바와 같으므로 iv) 청구항 2항 내지 5항도 기재불비에 해당한다고 판단된다.

5. 설문(2)의 해결

독립 청구항 제1항 및 종속 청구항인 제2항 내지 제5항 모두 기재불비에 해당된다. 나아가, 乙 이 청구한 무효심판의 결과도 예상컨대, 위와 같은 이유로 인용심결을 받게 될 것으로 판단된다.

6. 보 론

기능식 청구항과 관련하여, 특허법 규정을 면밀히 검토하고, 구체적인 특허심사기준의 제시를 통해 기능식 청구항 해석에 관한 명확하고 일관적인 기준을 정립하는 것이 향후과제라고 볼 수 있다.

<B - 2문>

[문 제]

甲은 '비소음형 자동변속기'라는 물건발명(이하 '이 사건 발명'이라 한다)의 특허권자이다. 甲은 자동변속기생산을 업으로 하는 乙과 이 사건 발명의 전용실시권 설정계약을 체결하면서, "기간: 2011년 1월 1일부터 2012년 1월 1일까지, 지역: 대한민국 전역, 실시내용: 생산·사용·양도·대여·수입·양도 및 대여의 청약"을 내용으로 하는 전용실시권 설정등록을 완료하였다. 반면, 甲이 乙과 체결한 '전용실시권 설정계약서'에는 "乙은 본 특허발명을 실시하고자 하는 경우, 甲에게 실시내용과 수량을 미리 알리고 甲의 승낙을 득한 후에 실시할 수 있다."는 특약이 있으나, 이러한 특약의 제한은 등록되지 아니하였다.

그런데, 乙은 甲의 승낙없이 2011년 1월 1일부터 2011년 6월 30일까지 이 사건 발명을 업으로서 실시하였다. 뿐만 아니라 乙은 실시사업을 丙에게 이전하지 않은 채, 2011년 7월 1일 甲의 동의없이 丙에게 이 사건 발명의 전용실시권을 이전하는 이전등록을 완료하였다. 아울러 乙은 2011년 7월 1일 이후에도 지속적으로 甲의 승낙없이 이 사건 발명을 업으로서 실시하였다. (단, 이 사건 발명의 특허성, 전용실시권 이전등록 신청 시 우리나라 특허청을 기망하는 행위가 있는지의 여부, 전용실시권 설정계약의 공정성 문제는 고려하지 말 것)

(1) 乙의 2011년 6월 30일 이전(以前)의 실시행위가 甲의 특허권을 침해하는지 여부를 판단하고, 甲의 구제수단을 설명하시오. (12점)

(2) 乙의 2011년 7월 1일 이후(以後)의 실시행위가 甲의 특허권을 침해하는지 여부를 판단하고, 甲의 구제수단을 설명하시오. (8점)

[해 설]**I. 문제의 소재 및 침해의 성립요건**

특허권자는 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는바(法94) 침해가 성립하기 위해서는

i) 유효한 권리가 존재하고 ii) 정당권원 없는 자가 iii) 보호범위 내에서 iv) 업으로서 실시하여야 한다.

II. 설문(1)에 대하여 - 특허권 침해 판단 및 구제 수단(11.6.30 이전의 실시) (12)**1. 전용실시권 일반론****(1) 전용실시권의 의의 및 성격**

전용 실시권이란 채권적 권리인 통상실시권과는 달리, 특허권자와 설정행위로 정한 범위 내에서

독점·배타적으로 특허발명을 업으로서 실시할 수 있는 물권적 권리를 말하며, 특허권자는 타인에게 특허권에 관하여 전용실시권을 설정할 수 있다(法100조1항).

(2) 전용실시권자의 지위

전용실시권자는 설정행위에서 정한 범위 내에서 업으로서 특허발명을 실시할 권리를 독점하는바 (제100조2항) 설정한 범위 내에서 특허권자라도 전용실시권자의 허락 없이 실시하면 전용실시권의 침해가 된다.(제94조 단서)

2. 乙이 甲의 특허권에 대한 전용실시권자인지 여부

(1) 전용실시권의 성립 및 효력발생(法100조1항2호)

- i) 특허권자와 전용실시권에 대한 계약을 맺고 ii) 전용실시권 설정등록한 경우 효력 발생한다. iii) 따라서, 전용실시권은 특허권자에 의한 설정계약에 의하여만 성립하고, 등록하지 아니하면 효력이 발생하지 아니한다.

(2) 사안의 경우

甲은 乙과 전용실시권 설정계약을 맺고, 설정등록을 완료하였는바 乙은 전용실시권자에 해당된다. 따라서, 乙은 설정행위로 정한 범위 내에서 특허발명을 독점적으로 실시할 정당한 권리가 인정된다.

3. 甲의 승낙 없는 乙의 실시가 전용실시권 범위 내의 실시인지 여부

(1) 전용실시권의 제한을 등록하지 않은 경우의 취급

최근 判例⁴⁾는 설정계약으로 전용실시권의 범위에 관하여 특별한 제한을 두고도 이를 등록하지 않으면 그 효력이 발생하지 않는 것이므로, 전용실시권자가 등록되어 있지 않은 제한을 넘어 특허발명을 실시하더라도 특허권 침해가 성립하는 것은 아니라고 하였다.

(2) 검토 및 사안의 경우

독점 배타적인 전용실시권의 특성 및 법적안정성의 측면을 고려할 때, 판례의 태도는 타당하다. 따라서, 전용실시권의 범위에 관한 제한은 등록하지 않으면, 효력이 발생하지 않는다는 法101조 1항2호에 따라, 乙이 특허발명을 실시하고자 하는 경우 甲에게 미리 승낙을 득하여야 한다는 등의 특약은 효력이 없으므로, 乙의 실시는 甲의 동의를 얻지 않았더라도 전용실시권 범위 내의 실시이다.

4. 乙의 실시(2011.6.30 이전)가 甲의 특허권을 침해하는지 여부

乙은 유효한 甲의 특허권을 보호범위 내에서 업으로서 실시하고 있으나, 전용실시권자로서 정당한 물권적 권원이 있으며, 그 제한(특약)은 효력이 없으므로 미리 甲의 승낙을 받지 않은 2011.1.1.부터 2011.6.1.까지의 乙의 실시는 전용실시권 범위 내 실시로서 甲의 특허권에 대한 침해가 아니다.

5. 甲의 구제수단

(1) 채무불이행 책임 - 손해배상 청구

乙의 실시는 특허법상 침해는 아니나, 甲과의 관계에 있어서 승낙을 받고 실시해야한다는 채무를 불이행했으므로 민사상 채무불이행을 이유로 한 손해배상을 청구할 수 있다.

(2) 제한의 등록

4) 2011도4645

전용실시권의 제한(특약)은 등록해야 효력이 발생하므로(法, 101조1항2호), 甲은 사후적으로 제한을 등록할 수 있으며, 만일 제한 등록 이후에도 乙이 계속하여 실시한다면 특허법상의 침해를 물을 수 있을 것이다.

(3) 계약해제 및 전용실시권 등록말소 청구

乙의 계약 위반을 이유로 乙과의 전용실시권 계약을 해제하고, 만일 乙이 계약해제에 동의하지 않는 경우 乙의 전용실시권에 대한 등록 말소를 청구 할 수 있을 것이다.

III. 설문(2)에 대하여 - 특허권 침해 판단 및 구제 수단(11.7.1 이후의 실시) (8)

1. 문제의 소재 및 실시행위의 독립성

실시행위 독립의 원칙이란 각각의 실시행위는 서로 독립적이므로 침해여부 역시 각각 독립적으로 판단해야 한다는 것을 말한다. 따라서 11.7.1 이후의 乙의 행위 중 i) 甲의 동의 없이 丙에게 전용실시권 이전등록을 한 행위 ii) 甲의 승낙없이 甲의 특허발명을 업으로서 실시한 행위를 나누어 각각의 행위별로 甲의 특허권을 침해하는지 판단하도록 한다.

2. 丙에게 전용실시권을 이전한 乙의 행위가 甲의 특허권을 침해하는지 여부

(1) 특허법상 실시의 태양 (法2조3호)

설문과 같은 물건 발명의 실시는 물건을 생산, 사용, 양도, 대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 말한다.(제2조3호 가목)

(2) 검토 및 사안의 경우 - 丙에게 전용실시권을 이전한 행위가 특허법상 실시인지 여부

法2조3호에서의 양도 등의 실시행위는 ‘특허발명의 물건 그 자체’를 의미하는 것이므로 乙이 丙에게 전용실시권을 이전한 행위는 특허법상의 실시에 해당되지 않는 바, 甲의 특허권을 침해하는 것이라고 볼 수 없다.

3. 乙이 여전히 甲 특허권에 대한 전용실시권자인지 여부

(1) 전용실시권 이전 (法100조3항)

전용실시권의 이전은 실시사업과 같이 이전하거나, 상속 기타 일반승계의 경우를 제외하고는 특허권자의 동의를 얻어야 한다.(제100조3항)

(2) 판례 및 사안의 경우

실시사업을 이전하지 않은 채 동의 없이 전용실시권을 이전한 것은 무효라고 판시한 判例⁵⁾
 및 상기 이전이 일반승계에 해당되지 않는다는 점을 고려할 때, 사안의 경우 丙에게로의 전용실시권 이전은 i) 실시사업의 이전 및 ii) 甲의 동의가 없으므로 무효라고 볼 수 있다. 따라서 乙은 丙에게 전용실시권을 이전등록 하였다고 하더라도, 여전히 甲의 특허권에 대한 전용실시권자에 해당한다.

4. 乙의 실시(2011.7.01 이후)가 甲의 특허권을 침해하는지 여부

乙은 유효한 甲의 특허권을 보호범위 내에서 업으로서 실시하고 있으나, 전용실시권자로서 정당한 물권적 권원이 있고, 설문(1)에서 살펴본 바와 같이 그 제한(특약)이 없으므로 미리 승낙을

5) 2010노3214

받지 않은 2011.7.1.부터의 乙의 실시는 甲의 특허권에 대한 침해가 아니다.

5. 甲의 구제수단

(1) 乙에 대하여 취할 수 있는 조치 - 채무불이행에 따른 손해배상청구 및 제한의 등록

甲은 설문(1)에서와 같이 승낙을 받고 실시하지 않은 乙에게 i) 민사상 채무불이행에 따른 손해배상을 청구하거나, ii) 전용실시권의 제한(특약)을 사후적으로 등록하는 조치를 취할 수 있으며, iii) 제한 등록 이후에도 乙이 계속하여 실시한다면 특허법상의 침해죄를 물을 수 있다. iv) 아울러, 乙의 계약 위반을 이유로 乙과의 전용실시권 계약을 해제 할 수 있다.

(2) 丙에 대하여 취할 수 있는 조치 - 전용실시권 등록말소 청구

i) 甲은 丙이 실시하고 있는 경우라면, 정당한 권원이 없음(전용실시권 무효)을 이유로, 침해 금지청구, 손해배상청구 및 침해죄 등의 민·형사상 조치를 취할 수 있으며, ii) 나아가 丙의 전용실시권 이전 등록은 무효라는 것을 이유로 하여 전용실시권 등록말소 청구를 할 수 있을 것이다.

앞서 말씀드린바와 같이, 본 풀이답안의 내용에 본인이 답안지에 작성하지 않은 내용이 포함 내지는 불포함 되어 있다거나, 논점 전개의 흐름에 있어 다소간의 차이가 있다 하더라도 심리적으로 크게 동요하실 필요는 없으며, 스스로의 논리를 믿으시면 분명히 좋은 점수를 받으실 것이라고, 강사가 아닌 선 경험자의 입장으로 말씀드리고 싶습니다.

시험이 진행되는 시간동안 마음속으로 진심을 담아 여러분들을 응원했습니다. 이제 친숙했던 하얀 답안지와 검정 펜은 여러분의 손을 떠났으니, 공부하시느라 지금껏 참아왔던 여러 가지 것들을 발표 때까지 걱정 없이 마음껏 즐기시길 바랍니다. 또한 누차 말씀 드리지만, 시험을 치른 느낌과 결과는 차이가 있을 수 있으니, 낙담하거나 혹은 자만하지 마시고 여러분들께 주어진 휴식의 기간을 마음껏 즐기시길 권합니다.

본 풀이답안에 대한 질문이나 고민이 있으신 분들은,
김남혁 변리사 supatent@daum.net 또는 장현욱 변리사 unthink83@naver.com 에게,
메일 주시면 답변드리겠습니다.
정말 수고하셨습니다 ^^